

DOI:10.14015/j.cnki.1004-8049.2023.02.006

李贞霏、彭德雷:“数字贸易例外规则的类型、演进及中国实践”,《太平洋学报》,2023年第2期,第68-80页。

LI Zhenfei, PENG Delei, “Types and Evolution of Digital Trade Exception Rules and China’s Responses,” *Pacific Journal*, Vol. 31, No. 2, 2023, pp.68-80.

数字贸易例外规则的类型、演进及中国实践

李贞霏¹ 彭德雷²

(1.上海市第一中级人民法院,上海 200336;2.华东理工大学,上海 200240)

摘要:数字贸易例外规则是数字贸易领域中寻求贸易自由与国家规制动态平衡的集中体现,大多散见于各双边、区域贸易协定及数字经济协定。这些数字贸易例外规则普遍参考了世界贸易组织协定中例外规则的设置模式、规范表达与功能定位,但在类型和规范内容上存在较大差异。其中,区域贸易协定规定的数字贸易例外规则适用情形及认定,存在扩张趋向。目前中国已缔结条约的数字贸易例外规则,与《全面进步的跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》等国际新规则中的同类条款相比存在差距。中国应妥善应对区域和全球性数字贸易规则谈判,更好参与世界贸易组织“电子商务工作计划”,充分利用例外规则为数字贸易发展提供的空间,推进数字领域制度型开放创新,推动数字经济的整体发展。

关键词:数字贸易;例外规则;贸易自由;规制主权

中图分类号:D996

文献标识码:A

文章编号:1004-8049(2023)02-0068-13

传统国际贸易法中,意在平衡全球贸易自由化目标与不同经济体自主规制权力的例外规则,历来被视为一种不完美但有必要保留的制度性安排。其中,世界贸易组织(以下简称WTO)框架下的《关税及贸易总协定》(以下简称GATT)第20条“一般例外”、第21条“安全例外”便是国际贸易法中例外规则的典型设定与

表述,被后续众多多边、区域及双边贸易协定所效仿。这种原则之外有为之的灵活性设计,^①考虑了各经济体不同的基本国情、规制模式与价值理念,为各方采取贸易规制措施、进行自由裁量保留了空间。然而,对例外规则的适用一旦行差踏错,会引发滥用例外设置贸易壁垒、进行贸易保护等诸多争议,导致例外规则沦为国

收稿日期:2022-08-03;修订日期:2023-02-18。

基金项目:本文系国家社会科学基金项目“数字贸易框架下跨境数据流动的国家规制与国际治理研究”(19CFX083)、上海市教育法学人才项目(2020JYFXR041)、上海市浦江人才项目(PJ20190002076)的阶段性研究成果。

作者简介:李贞霏(1990—),女,山西晋中人,上海市第一中级人民法院法官助理,法学博士,主要研究方向:国际经济法;彭德雷(1984—),男,江西宜春人,华东理工大学法学院院长、教授、博士生导师,世界贸易组织年度贸易报告外审专家,华理—临港自贸区创新研究院研究员,上海市浦江学者,兼任上海交通大学亚洲法律中心研究员,主要研究方向:国际经济与贸易及相关法律制度。

* 感谢《太平洋学报》编辑部和匿名审稿专家提出的建设性修改意见,文中错漏由笔者负责。

① Krzysztof J. Pelc, *Making and Bending International Rules: The Design of Exceptions and Escape Clauses in Trade Law*, Cambridge University Press, 2016, p. 44.

际贸易法的“阿喀琉斯之踵”。^①

自第三次工业革命以来,传统贸易不断接受着数字技术深刻且全方位的升级改造,形成了包括数字赋能货物贸易、数字赋能服务贸易以及数字产品贸易等在内的众多数字贸易新形式。全球范围内数字技术与网络空间实现了前所未有的互联互通,对数字贸易领域平衡贸易自由与规制主权提出了更加严峻且敏感的挑战。作为两者平衡的产物,数字贸易例外规则以不同的形式呈现,不仅包括区域贸易协定中的例外专章、数字贸易专章特定条款下的例外规定,还涉及区域贸易协定援引的WTO例外规则。出于对新型经贸与网络活动的审慎规制,数字贸易例外规则规定的适用情形与自主认定空间存在一定的扩张趋势。对此,在参与全球数字贸易国际规则治理中,中国应如何设定及适用数字贸易例外规则,如何更好地推动数字贸易发展与合作,值得关注。为此,对数字贸易例外规则的类型、规范差异与发展趋向展开研究,在数字贸易迅猛发展的当下显得尤为必要。

一、数字贸易例外规则的规范类型

多边贸易规则体系中广义的例外规则,包括了针对非歧视待遇原则及个别部门市场准入等作出的承诺例外,也包括了表面上违反所作承诺的不符措施因公共政策与国家安全等原因而在一定情形下无需承担责任的免责例外。^②承诺例外往往是各方在进行开放性与自由化贸易谈判时所作的互惠选择,一旦承诺落地,后续发生的不符措施能否免责则主要取决于免责例外条款能否适用。因此,我们将集中探讨免责性数字贸易例外规则。数字贸易例外规则散见于多边、区域及双边贸易协定,内容丰富、形式多样。为了更有效地把握规则发展趋向,有必要先对数字贸易例外规则法律渊源的规范性差异进行梳理与分析。

1.1 多边协定中例外规则对数字贸易的适用

较之于数字贸易活动,WTO规则存在文本

滞后性与适用不确定性。^③WTO多边贸易协定主要形成于20世纪90年代中叶前,彼时WTO成员方对数字技术的了解、认识与预期远远赶不上数字技术的现实发展步伐。因此,在WTO规则文本中,没有关于数字贸易的概念界定及规则要求,在成员方缔约时的意图层面,也很难直接推测各方存在规制数字贸易活动的共同意思表示。尽管WTO既有协定中已经存在相对完善的例外规则体系,却无法直接得出WTO例外规则适用于数字贸易的结论,无法武断判定WTO例外规则属于多边贸易协定中的数字贸易例外规则。多边贸易体制中较为成熟的例外规则体系,由一般例外条款与安全例外条款组成。前者主要指GATT第20条^④与《服务贸易总协定》(以下简称GATS)第14条,^⑤后者主要包括GATT第21条、GATS第14条之二与《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称TRIPS)第73条。^⑥另外,诸如《与贸易有关的投资措施协议》(以下简称TRIMS)第3条还规定,GATT中的所有例外应适时适用于该协定。上述一般

① Hannes L. Schloemann and Stefan Ohlbuff, “‘Constitutionalization’ and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence,” *American Journal of International Law*, Vol. 93, No. 2, 1999, p. 426.

② 谭观福:“数字贸易规制的免责例外”,《河北法学》,2021年第6期,第103页。

③ 赵龙跃、高红伟:“中国与全球数字贸易治理:基于加入DEPA的机遇与挑战”,《太平洋学报》,2022年第2期,第14页。

④ GATT第20条主要规定:本协定的规定不得解释为阻止缔约方采用或实施以下措施,但对情况相同的各国,实施的措施不得构成武断的或不合理的差别待遇,或构成对国际贸易的变相限制:(a)为维护公共道德所必需的措施;(b)为保障人民、动植物的生命或健康所必需的措施;(c)有关输出或输入黄金或白银的措施;(d)为保证某些与本协定的规定并无抵触的法令或条例的贯彻执行所必需的措施……。

⑤ GATS第14条主要规定:只要这类措施的实施不在情况相同的成员间构成武断的、或不合理的歧视,或构成对服务贸易的变相限制,则本协定的规定不得解释为阻止任何成员采用或实施以下措施:(a)为保护公共道德或维护公共秩序而必需的;(b)为保护人类、动物或植物的生命或健康而必需的;(c)确保遵守与本协议规定不相抵触的法律或法规所必需的……。

⑥ GATT第21条、GATS第14条之二、TRIPS第73条规定的安全例外,表述高度一致:该协定不得解释为:(a)要求成员提供其认为如披露则会违背其基本安全利益的任何信息;或(b)阻止成员采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动……或(c)阻止成员为履行《联合国宪章》项下的维持国际和平与安全的义务而采取的任何行动。

例外条款与安全例外条款,均属于WTO允许成员方免于承担协定所规定义务及所作承诺的特殊制度安排,成员方通过援引例外条款可以为违反协定义务及承诺的不符措施寻求免责。但是,两种例外条款意在维护的国家及社会特定利益存在差别,可供援引的具体免责事由有所不同。一般例外条款着眼于维护公共道德、保护环境与资源、维护公共秩序、实现公共政策目标等广泛且特定的社会公共利益,安全例外条款则围绕国家安全,特别是基本安全利益这一根本性权利基础而展开。由于国家安全利益的更高敏感性与战略性,安全例外条款的规范结构与援引要求也不同于一般例外条款。WTO一般例外条款采用了在条款序言明确适用条件、在条款子项列举具体适用情形的双层规范结构。因此,援引一般例外条款不仅须证明不符措施基于合法目标而采取,且该措施的实施方式不得构成任意或不合理的歧视或变相的贸易限制,也不得超过实现该目标的必要限度。然而,WTO安全例外条款则仅对与基本安全利益相关的若干情形做了列举,未在条款序言中设定具体适用条件,足见WTO对成员方自我安全利益保护的高度尊重。

值得关注的是,诸多区域贸易协定,如欧盟—加拿大《综合经贸协定》(以下简称CETA)第16.2.1条、美国—澳大利亚自贸协定第16.1条、中国—韩国自贸协定第13.1条、中国—新西兰自贸协定升级议定书新增第19章的第2.1条等,明文规定了WTO协定对影响电子商务与数字贸易的措施的适用性。因此,对于这些区域贸易协定的缔约方而言,WTO协定中的例外规则将与透明度、非歧视、减少不必要的贸易壁垒等原则以及市场开放相关承诺一起,对缔约方的数字贸易规制措施形成约束。^①

另外,WTO争端解决实践也在一定程度上肯定了涉及例外条款在内的WTO规则适用于数字贸易。美国博彩案是WTO争端解决机构审理的第一起通过数字技术提供服务而引发的争议,也是第一起涉及并遵循了技术中立原则的案件。^②基于文本客观证据与技术中立原则,

WTO争端解决机构对成员方缔约意图进行了演化解释、对新情势下成员方规范性预期进行了推断,^③认为虽然很多成员方在缔约时未曾考虑到数字交付的服务贸易,但成员方在模式1“跨境提供”中对各服务部门市场准入的承诺适用于通过所有数字技术提供的同类服务。数字赋能的服务贸易将被视为数字经济背景下常规服务贸易的变体,适用于WTO成员方在该服务部门下作出的具体承诺。^④同时,争端解决机构还遵循了一般例外的常规分析路径,对美国援引GATS第14条一般例外的主张进行了非常详尽的解释,得出美国的不符措施未满足例外条款序言要求的最终结论。^⑤不过,WTO争端解决裁决并非判例,对数字贸易的相关问题也涉及有限,多边贸易规则中的例外条款并不能被直接视为多边协定中的数字贸易例外规则。同时,由于数字贸易与货物贸易、服务贸易的属性关系划分不明确,GATT与GATS例外条款如何分别适用于各类数字贸易也存在较大争议。这些问题还有待WTO成员方在电子商务议题下的进一步谈判与确认。

1.2 区域协定中的数字贸易例外规则

新近,各类涉及甚至以数字贸易为核心的区域贸易协定、经济伙伴协定,在全球范围内发展迅速。除涉及电子商务基础条款的早期区域贸易协定外,美国主导的《跨太平洋伙伴关系协定》(以下简称TPP)、《美墨加协定》(以下简称USMCA)、《美日数字贸易协定》(以下简称USJDTA),欧盟与加拿大签署的CETA,东盟与中国合作的《区域全面经济伙伴关系协定》(以

① Javier López González and Janos Ferencz, *Digital Trade and Market Openness*, OECD Trade Policy Papers, No.217, 2018.

② Panagiotis Delimatsis, "The Puzzling Interaction of Trade and Public Morals in the Digital Era," in Mira Burri and Thomas Cottier, *Trade Governance in the Digital Age: World Trade Forum*, Cambridge University Press, 2012, p. 293.

③ Sacha Wunsch-Vincent, *The WTO, the Internet and Trade in Digital Products EC-US Perspectives*, Hart Publishing, 2006, p. 346.

④ 彭岳:“数据本地化措施的贸易规制问题研究”,《环球法律评论》,2018年第2期,第185页。

⑤ Appellate Body Report, US - Gambling, WT/DS285/AB/R, 7 April 2005, paras. 266-372.

下简称 RCEP),新加坡等数字经济新力量驱动的《新加坡—新西兰—智利数字经济合作协定》(以下简称 DEPA)、《新加坡—澳大利亚数字经济协定》(以下简称 SADEA)等纷纷达成,共同推进了数字贸易规范体系与治理结构的不断完善。通过梳理这些代表性的区域贸易协定,我们可以发现其中的数字贸易例外规则大致可以分为以下两类:

(1) 区域协定中整体设置的例外专章或条款

区域贸易协定中最常见的数字贸易例外规则,是针对协定整体而设定的例外专章或条款。据统计,在 2000 年至 2021 年年中达成的超过 340 个区域贸易协定中,有 113 个包含了电子商务及数字贸易条款,有 83 个设置了电子商务及数字贸易专章,有 50 个明确提出 WTO 规则适用于电子商务与数字贸易。^① 这些区域贸易协定的例外专章或条款,高度参照了 WTO 协定中例外规则的设定模式及规范表述,亦可适用于与电子商务及数字贸易相关的不符措施。例如,CPTPP 第 29 章、USMCA 第 32 章、CETA 第 28 章、RCEP 第 17 章、DEPA 第 15 章,均属于包含一般例外与安全例外的例外专章。

比较其中的一般例外规则,各个区域协定通过援引 GATT 与 GATS 一般例外条款的形式设置了一般例外,即使没有直接援引,如 CETA 第 28.3 条,也采用了与 GATT 和 GATS 一般例外一致的具体表述。不过,由于对数字贸易法律属性的界定争议,各方援引 WTO 一般例外规则的具体方式大不相同,详见表 1。CPTPP 第 29.1.3 条、USMCA 第 32.1.2 条规定,经必要修订后的 GATS 第 14 条(a)(b)(c)款,构成该协定的一部分,从而适用于电子商务与数字贸易章节,但这不代表缔约方对数字产品属于货物还是服务的判断。与此不同,USJDTA 第 3 条、RCEP 第 17 章第 12 条与 DEPA 第 15.1.3 条等则规定 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条(a)(b)(c)款经必要修改后,都可以构成该协定的一部分。

比较其中的安全例外规则,CETA 第 28.6

条与 WTO 安全例外条款基本一致;CPTPP 第 29.2 条、USMCA 第 32.2 条、DEPA 第 15.2 条三者相对一致,对 WTO 安全例外进行了两处重要修改,一是完全取消了 GATT 第 21 条(b)款等对基本安全利益的三种情形列举,并将(b)(c)两款合并表述,二是在 GATT 第 21 条(c)款缔约方为维护国际和平与安全义务而采取必需措施的例外情形前增加了“其认为”(it considers)的前缀;^②RCEP 第 17 章第 13 条没有对维护国际和平与安全的例外情形增加“其认为”前缀,但在缔约方采取其认为保护基本安全利益所采取必需行动的例外情形内,增加了“为保护包括通讯、电力和水利基础设施在内的关键的公共基础设施”与“国家紧急状态”的情况。^③ 另外,虽然 USJDTA、SADEA 等数字经济伙伴协定没有设置例外专章,但协定中也会设置单独的例外条款。例如,USJDTA 第 4 条便设置了与 CPTPP 一致的安全例外条款。

(2) 数字贸易专章中针对特定条款的例外规定

在区域贸易协定例外专章之外,区域贸易协定数字贸易专章中还存在另一类专门针对数字贸易特定条款而设置的免责例外,主要涉及计算设施位置、跨境数据传输和源代码三项条款。数据流动是进行数字贸易的基本前提与重

① 数据来源:“Trade Agreements Provisions on Electronic-commerce and Data,” University of Lucerne, <https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/managing-director-internationalisation/research/taped/>, 访问时间:2023 年 2 月 16 日。

② 安全例外条款中“其认为”措辞赋予了缔约方援引安全例外条款时一定的自由裁量权利。如 CPTPP 第 29.2 条规定,本协定中的任何内容均不得解释为:(a) 要求一方提供或允许查阅其认为违反其基本安全利益的信息;或(b) 不允许一方采取其认为履行其在维持或恢复国际和平或安全方面的义务所必需的措施,或保护其自身的基本安全利益。与 GATT 第 21 条(c)款相比,上述条款增加了“其认为”表述,更加强调了缔约方援引此种安全例外情形的自由裁量权。

③ RCEP 第 17 章第 13 条主要规定,本协定的任何规定不得解释为:(一) 要求任何缔约方提供其认为如披露则违背其基本安全利益的任何信息;(二) 阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动;1.……3. 为保护包括通讯、电力和水利基础设施在内的关键的公共基础设施而采取的行动;4. 在国家紧急状态,或战时,或国际关系中的其他紧急情况下采取的行动;或者(三) 阻止任何缔约方为履行其在《联合国宪章》项下维护国际和平与安全的义务而采取的任何行动。

要方式,因此,对数据流动的规制成为了数字贸易规则的子议题之一,前述三项事关数据存储、流动及披露的条款,也通过“原则+例外”的形式展现了数据自由流动与数据规制权的平衡。通过梳理这三项比较典型的条款,我们可以清楚地发现:全球主要的数字贸易大国大多认同数字贸易规制中的公共政策例外,也相对肯定各方在特定情形下的自主规制权,详见表 2。其中,特定条款下的公共政策例外普遍设置了与

WTO 一般例外规则一致的适用要求,即该不符措施的适用方式不会构成任意或不合理的歧视或变相的贸易限制,不符措施也不会超出实现该公共政策目标所需的必要限度。特定情形下的规制与司法例外,与 GATT 第 20 条(d)项、GATS 第 14 条(c)项的确保遵守法规例外相比,有异曲同工的功能定位,但是前者没有明文设定与后者一致的适用要求。

表 1 区域贸易协定中例外专章对 WTO 一般例外的援引

适用情形分类		具体条款示例
援引 WTO 一般例外条款	只援引 GATS 第 14 条	CPTPP 第 29.1.3 条、USMCA 第 32.1.2 条
	同时援引 GATT 第 20 条与 GATS 第 14 条	DEPA 第 15.1 条、SADEA 第 14 章第 3 条、RCEP 第 17 章第 12 条、USJDTA 第 3 条、中国—韩国自贸协定第 16.2 条

资料来源:作者自制,下表同。

表 2 区域贸易协定数字贸易专章中特定条款下的例外规定^①

条款	跨境数据传输	计算设施位置	源代码
CPTPP	第 14.11 条:公共政策例外	第 14.13 条:公共政策例外	第 14.17 条:特殊情形下的规制与司法例外
USMCA	第 19.11 条:公共政策例外	第 19.12 条:未设置例外	第 19.16 条:特殊情形下的规制与司法例外
USJDTA	第 11 条:公共政策例外	第 12 条未规定免责例外,但规定了针对金融服务提供者的承诺例外	第 17 条:特殊情形下的规制与司法例外
DEPA	第 4.3 条:公共政策例外	第 4.4 条:公共政策例外	未规定源代码条款
SADEA	第 23 条:公共政策例外	第 24 条:公共政策例外	第 28 条:特殊情形下的规制与司法例外
RCEP 第 12 章	第 15 条:公共政策例外、基本安全利益例外	第 14 条:公共政策例外、基本安全利益例外	未规定源代码条款

二、数字贸易例外规则的演进趋势

上述多边及区域贸易协定中的数字贸易例外规则,总体依循了 WTO 多边贸易体制对例外规则的类型设置,即一般例外与安全例外两大类。前者涉及例外专章中的一般例外条款,也

包括数字贸易特定条款下的公共政策例外及规制与司法例外,下文将这些共享相似规范表达与功能定位的例外条款统称为“一般例外规则”,方便对其进行区别于安全例外的具体分析;后者主要指例外专章中的安全例外条款。从 WTO 电子商务诸边谈判已公开的提案来看,谈判各方也采用了同样的数字贸易例外规则分

^① CPTPP 第 14.4 条、USMCA 第 19.4 条、USJDTA 第 8 条、DEPA 第 3.3 条、SADEA 第 6 条还规定了数字产品非歧视待遇,并规定了数字产品非歧视待遇不适用的若干情形,如知识产权权利义务例外、政府补贴补助例外、广播行业例外。但是,此类采用“不适用于”(not apply to)表述的例外情形属于对非歧视待遇的承诺例外,并不是违反承诺后的免责例外,故不属于本文聚焦讨论的范畴。RCEP 未规定数字产品非歧视待遇。

类与条款设置形式。比较这些既定的多边及区域数字贸易例外条款,并进一步结合各方在WTO电子商务谈判进程中的数字贸易例外规

则提案来看,这些具体条款文本虽不尽相同,但总体呈现出增设例外情形、扩展援引例外条款的自我裁量空间等发展趋势,详见表3。

表3 数字贸易例外规则的发展趋势

类型	适用情形的领域拓展	适用裁量的空间拓展
一般例外	在跨境数据传输、计算设施位置、源代码领域都要求单独设定公共政策例外;个人隐私保护、打击虚假信息不断丰富公共政策例外及规制例外的合理目标	特定条款下的一般例外未设定不符措施的必要性与非歧视条件;个别自贸协定将对不符措施是否为实现公共政策目标所必要的判断权交给了缔约方,而非争端解决机构
安全例外	基本安全利益不再局限于传统军事安全,还包括数据安全、网络安全、通讯基础设施安全等非传统安全类型	各方普遍对“其认为”措辞进行了强化,从而为缔约方援引安全例外条款争取更大的自由裁量权利

2.1 数字贸易例外规则适用情形的拓展

数字贸易一般例外与安全例外的适用情形都存在扩张倾向,反映了世界各国对于数字经济新业态的审慎态度,需要国际贸易规则给予各国规制数字贸易的探索空间。同时也表明虽然欧美等数字大国掌握了高水平数字贸易协定的话语权,但各国依然在诸边及多边层面积极争取对数字贸易的自主规制权利。

(1) 数字贸易一般例外适用情形的拓展

美国、欧盟等发达经济体试图凭借数字技术与贸易的强大竞争力,^①压缩区域贸易协定中公共政策等一般例外的适用空间,但处于不同发展阶段的其他经济体则希望在数字贸易全球治理的探索初期保留更多一般例外适用情形。比起CPTPP,USMCA不但取消了计算设施位置条款的公共政策例外、源代码条款中的若干例外,还取消了在跨境数据传输条款、计算设施位置条款中确认缔约方可能存在各自规制要求的表达。在各方递交WTO的电子商务提案中,美国、^②欧盟^③只在源代码条款中提出了成员方合法规制目标的例外;然而,日本^④与加拿大则认为跨境数据传输、计算设施位置、源代码都可以设定公共政策例外,二者区别在于加拿大肯定的是源代码条款的规制例外,^⑤另外加拿大还提出了个人信息保护的合法规制例外;^⑥新加坡提案与DEPA一致,建议设置对前两项特定条款的公共政策例外,没有设置源代码条款;^⑦发展中国家巴西还提议,对跨境数据流动作适当规

制限制是不可避免的,因此必须结合数字环境新特点对GATS一般例外与安全例外进行适应性改进,^⑧跨境数据传输的公共政策例外以及其他一般例外应被充分考虑。^⑨总之,各个国家及地区倾向于为数字贸易一般例外规则设定较多的适用情形,保留较大的适用空间。

值得思考的是,即使未来达成的数字贸易诸边协定设定了较多的一般例外情形,各方对数字贸易一般例外情形的理解仍会存在差异。特别是公共道德、公共秩序等社会性概念,其内涵有特定的地域与历史背景,与不同国家及地

① 季剑军:“美日韩三国制度型开放路径比较及其启示”,《亚太经济》,2021年第6期,第74页。

② WTO, Joint Statement on Electronic Commerce Initiative, Communication from the United States, INF/ECOM/5, 25 March 2019, p. 2.

③ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, EU Proposal for WTO Disciplines and Commitments Relating to Electronic Commerce, Communication from the European Union, INF/ECOM/22, 26 April 2019, p. 3.

④ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce Initiative, Proposal for the Exploratory Work by Japan, INF/ECOM/4, 25 March 2019, pp. 2, 4.

⑤ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from Canada, INF/ECOM/34, 11 June 2019, pp. 5-6.

⑥ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from Canada, Additional Text Proposal - Personal Information Protection, INF/ECOM/58, 19 October 2020, pp. 2-3.

⑦ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from Singapore, INF/ECOM/25, 30 April 2019, p. 3.

⑧ WTO, Exploratory Work on Electronic Commerce, Non - Paper from Brazil, INF/ECOM/3, 25 March 2019, p. 5.

⑨ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from Brazil, INF/ECOM/27/Rev.1, pp. 5-6.

区的经济运转、社会发展、文化观念、道德传统等密切相关。因此,各WTO成员方会被赋予一定的政策空间,允许其根据自身价值与制度尺度来确定其关境内公共道德与公共秩序的内涵及保护水平。较之于抽象的公共道德与公共秩序,规制与司法例外、确保遵守法规的例外更加具象,与防止欺诈及处理合同违约、保护个人隐私、安全等GATS第14条(c)项列举的法律法规直接相关,但并不局限于这三种情形,只要是本身不违反WTO协定的法律法规,都可以构成援引确保遵守法规例外的基础。^①3D打印、区块链、虚拟现实等数字技术为人类经济、社会与文化带来巨大变化,各国无论是在网络空间公共道德与公共秩序范畴,还是在互联网法律法规完善的法制化建设中,都在不断摸索各类规制措施的目的、方法与范围等。在数字经济的探索期内,违反数字贸易协定与承诺、造成间接限制数字贸易影响的不符措施,或许都会尝试援引公共道德、公共秩序、公共政策及确保遵守法规等一般例外条款来免责,数字贸易一般例外规则的实际适用场景或许会根据实践发展得到进一步拓展。

(2) 数字贸易安全例外适用情形的拓展

区域贸易协定中数字贸易安全例外规则规定的适用范畴,大多也存在扩张倾向。各方对国家安全内涵的认识已经发生改变,在过去传统的军事安全威胁之外产生了诸如数据资源安全、信息安全、数字技术安全、网络安全等非传统安全威胁。^②在数字技术颠覆性改造传统贸易的当下,在世界各国摸索互联网时代合法合理规制模式的初期,各方在区域贸易协定及WTO电子商务谈判中选择了相对保守的国家安全理念。CPTPP、USMCA、DEPA等区域贸易协定取消了WTO安全例外条款对“维护成员基本安全利益所必需的三类行动”列举,代之以“为保护其基本安全利益的任何措施”;RCEP在保留WTO安全例外列举的基本安全利益情形基础上,增加了“通讯、电力和水利关键的公共基础设施”等关乎基本安全利益的情形,还在跨境数据传输与计算设施位置条款中设置了基

本安全利益例外。另外,加拿大递交WTO的提案中还提出了个人信息保护的国家安全例外。^③面对影响不能完全估量并有效控制的数字时代新安全议题,各方普遍秉持了相对保守的国家安全底线,因此,网络安全、数据安全或将成为WTO电子商务谈判及数字贸易争端案件中安全例外情形的重要组成部分。

具体到对“基本安全利益”的理解,其内涵也在跟随数字时代的发展而不断演进。过去,国际社会一般认为,基本安全利益较之于安全利益而言更为狭义,通常指保护领土与人民免受外部威胁、维护国内法律与公共秩序等与一国典型职能密切相关的具体利益,^④与WTO安全例外规则中核物质、武器、战争等威胁国际和平的军事情况更加相关。但在数字时代,网络空间的军事化对抗也可能发生,而且网络空间作战的杀伤力与作战效能或许还会高于现实中的军事战斗。因为国家各项公务活动与人民生活已高度依赖数字网络与通讯基础设施,对关键通讯基础设施的破坏、功能打击或数据盗取,势必严重威胁国家基本安全利益。

2.2 数字贸易例外规则自主裁量的空间拓展

数字贸易例外规则虽然都高度参考了WTO例外规则,但却通过强化“其认为”等用词来积极争取例外规则适用的更大自主规制空间,特别是数字贸易安全例外规则。目前数字贸易领域的争端纠纷还不明显,针对数字贸易例外规则能否以及如何适用的法律解释与探讨还相对较少。其原因,一方面是数字贸易是近年来新兴的贸易形式,各方仍处于自然发展与初步探索状态,另一方面是诸多区域贸易协定明确排

^① Panel Report, Argentina – Financial Services, WT/DS453/R, 30 September 2015, paras. 7.595–7.596.

^② 佟家栋、张千:“数字经济内涵及其对未来经济发展的超常贡献”,《南开学报(哲学社会科学版)》,2022年第3期,第31页。

^③ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from Canada, Additional Text Proposal – Personal Information Protection, INF/ECOM/58, 19 October 2020, p. 3.

^④ Panel Report, Russia – Traffic in Transit, WT/DS512/R, 5 April 2019, paras. 7.130–7.132.

除了争端解决对电子商务与数字贸易条款或章节的适用。不过,考虑到数字贸易例外规则要么直接援引 WTO 例外条款,要么高度借鉴 WTO 例外规则的表述,缔约方能在多大程度上自主判定数字贸易例外能否适用,可以参考过往 WTO 争端解决案件中对此问题的分析。

(1) 数字贸易一般例外适用认定的拓展

数字贸易一般例外规则普遍参考 WTO 一般例外条款模式,设定了一般例外的适用要件,即同时满足①不符措施的适用方式不会构成任意或不合理的歧视、或变相的贸易限制,②不符措施也不会超出实现该公共政策目标所需的必要限度。但 CPTPP、USMCA、USJDTA、SADEA 等协定在源代码条款下设定的规制与司法例外,并没有像 GATT 第 20 条(d)项与 GATS 第 14 条(c)项的确保遵守法规例外一样设定不符措施的必要性与非歧视双重条件,仅要求具备防止未经授权而披露的保障措施。争端解决实践中,前述两项适用要件是否满足主要由争端解决机构来做出判断。通常来说,不符措施的必要性标准是相对客观的,争端解决机构可以依据法规文本、立法历史、政府机构或官员的声明、不符措施的结构设置与操作情况、以及申诉方提供的相反证据等,作出独立客观的评估。①争端解决机构还会展开一系列“权衡与平衡”,考察不符措施对其所追求目标的贡献以及对国际贸易造成的不利影响,考察是否存在利益相关方合理预期可被采用的符合 WTO 法的替代措施、或更少违反 WTO 义务的合理可用的替代措施,进而再将不符措施与可能的替代措施进行比较,并根据所涉利益的重要性得出必要性判断的最终结果。②

然而,RCEP 在跨境数据传输条款、计算设施位置条款下设定的公共政策例外,则存在一项较大差异,根据 RCEP 第 12 章第 14、15 条及其脚注规定,实施合法公共政策的必要性应当由实施的缔约方决定。RCEP 的差异化规定,无疑将进一步增加数字贸易不符措施必要性、替代措施可用性的判断争议。不同经济体之间的数字鸿沟持续扩大,③导致各方国内对网络空间

公共秩序维护与公共政策设定的目标、方式与水平各不相同,也导致各方有条件或有可能采用的规制及技术措施很难一致。尤其是广大发展中经济体,在数字基础设施建设、数字技术开发与应用、数字产业发展乃至数字化监管的能力与手段等方面,均落后于发达经济体。以跨境数据传输为例,为了实现隐私保护等公共政策目标,欧盟与中国很可能分别基于《通用数据保护条例》(GDPR)第 5 章“数据跨境传输机制”、《个人信息保护法》第 3 章“个人信息跨境提供的规则”而采取不同的不符措施。中国的措施或许会被质疑并非为了隐私保护,欧盟的措施一样也可能被质疑只是为了增加本地数据中心、增强国内数字产业优势。④各方对数字贸易领域不符措施必要性及替代措施的判断面临极大争议,即使未来达成的 WTO 电子商务诸边规则将措施的必要性判断权授予争端解决机构,争端解决机构也会面临客观公允性的严肃考验。

(2) 数字贸易安全例外适用认定的拓展

数字贸易安全例外规则适用扩张更突出的表现是,各方更加强调对不符措施是否属于安全例外适用情形的自主认定空间。CPTPP、USMCA、DEPA 等区域贸易协定普遍强化了数字贸易安全例外中的“其认为”措辞,RCEP 第 12 章第 14 条、第 15 条甚至还明确规定了其他缔约方不得对缔约方为保护其基本安全利益所采取任何必要措施提出异议。在各方提交 WTO

① 相关 WTO 案例,可参见:Appellate Body Report, US - Gambling, WT/DS285/AB/R, 7 April 2005, paras. 304-311; Appellate Body Report, US - Shrimp, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, paras. 158-159; Appellate Body Report, US - Tuna II (Mexico) (Article. 21.5 - Mexico), WT/DS381/AB/RW/USA, WT/DS381/AB/RW2, 14 December 2018, para. 7.316; Appellate Body Report, US - Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 25.

② Appellate Body Report, US - Gambling, WT/DS285/AB/R, 7 April 2005, paras. 304-311.

③ UNCTAD, Trade and Development Report 2020, From Global Pandemic to Prosperity for All: Avoiding Another Lost Decade, UNCTAD/TDR/2020, 2021, p. 16.

④ Neha Mishra, "Privacy, Cybersecurity, and GATS Article XIV: A New Frontier for Trade and Internet Regulation?" *World Trade Review*, Vol. 19, No. 3, 2020, p. 359.

电子商务谈判的案文提案中,加拿大与日本认为对 GATT 第 21 条与 GATS 第 14 条之二进行必要修改就可以构成数字贸易安全例外规则,没有提出对“其认为”表述的具体修订;巴西则对 WTO 安全例外规则进行了具体改写,在“按照《联合国宪章》规定的维持国际和平与安全的义务而采取任何行动”的例外情形下设置了“其认为”表述。^① 通观这些区域贸易协定和 WTO 谈判案文提案中的安全例外规则,可以看出各方在安全例外情形认定问题上还存在较大不确定性:既希望通过区域性规则来扩张自主判定的裁量空间进而影响形成中的诸边规则,又不得不为了更广泛国际合作而保持适度克制。

数字贸易安全例外在规范文本层面对“其认为”的强调,是否意味着实践中完全由援引安全例外的缔约方自行认定其不符措施是不是维护基本安全利益所必需的,而无需接受争端解决机构的管辖与客观审查? 争端解决实践中,特别是俄罗斯运输限制措施案中,俄罗斯曾强调安全例外规则中的“其认为”权利,提出 WTO 无法为某个成员决定其基本安全利益是什么、为保护这种基本安全利益需要采取什么行动、披露什么信息可能违背该成员的基本安全利益、什么构成国际关系中的紧急状态、在特定情况下是否存在这种紧急情况。该案第三方美国也认为,GATT 缔约方和 WTO 成员反复认可了“其认为”呈现的成员方固有权利——其对国家安全事项的最终判断权。但是,澳大利亚、巴西、中国、欧盟、日本、新加坡等成员则更加认同乌克兰的观点:为了保持滥用安全例外与遵守 WTO 义务之间的平衡,专家组有权依据《关于争端解决规则与程序的谅解》(DSU)来对不符措施与基本安全利益目标之间是否存在足够且合理的联系、对不符措施的实施是否符合善意原则,进行审慎客观的审查。专家组最终认定,无论是在成员方过往的声明记录中,还是在安全例外条款的谈判历史中,各方对于安全例外的自行认定问题并不存在广泛共识,也没有形成嗣后惯例,GATT 第 21 条(b)项“其认为”的表述不代表安全例外能否适用完全由成员方自

行决断,专家组有权对“所必需”问题进行客观审查。^②

尽管存在规范层面的自主裁量空间扩张,未来数字贸易争端中对援引安全例外的认定,可能仍将遵循俄罗斯运输限制措施案中专家组的裁判逻辑。因为一方面,各方在 WTO 电子商务谈判的安全例外条款案文提案中普遍设定了“所必需”的限定要求,“其认为”与“所必需”共存的表述意味着数字贸易不符措施援引安全例外,同样需要考虑条约缔结时对主权国家的高度尊重与合理限制双重考虑;^③ 另一方面,各方在 WTO 电子商务谈判的争端解决条款案文提案中均没有明文排除争端解决机构与程序对安全例外事项的管辖与适用。^④

三、数字贸易例外规则演进下的中国实践

截至 2022 年 6 月 30 日,中国已签署的贸易协定及其升级协定中,很多都设置了电子商务专章,详见表 4。对比中国早期设定电子商务专章的区域贸易协定、2022 年正式生效的 RCEP 以及正在申请加入的 CPTPP 与 DEPA,可以把握中国已签署区域贸易协定中数字贸易例外规则的发展过程与现状。中国也在积极参与 WTO 电子商务谈判,致力与其他经济体一起形成更广泛的规范性共识,化解数字贸易国际规则碎片化与滞后性难题。^⑤ 坚定维护并践行多边主义,推进 WTO 电子商务谈判,可以增强诸边及

① WTO, WTO Electronic Commerce Negotiations, Consolidated Negotiating Text - December 2020, INF/ECOM/62/Rev.1, 14 December 2020, p. 86.

② Panel Report, Russia - Traffic in Transit, WT/DS512/R, 5 April 2019, paras. 7.28, 7.31-7.52, 7.80-7.104.

③ 彭德雷、周围欢、杨国华:“国际贸易中的‘国家安全’审视——基于美国‘232 调查’的考察”,《国际经贸探索》,2018 年第 5 期,第 97 页。

④ WTO, WTO Electronic Commerce Negotiations, Consolidated Negotiating Text - December 2020, INF/ECOM/62/Rev.1, 14 December 2020, p. 89.

⑤ 黄家星:“国际数字贸易规则碎片化:现状、成因及应对”,《太平洋学报》,2022 年第 4 期,第 70 页。

多边规则的领导力,消减规则碎片化所增加的从事数字贸易以及规制数字贸易的制度成本,降低各方发生数字贸易摩擦的可能性。在以各类区域贸易协定为先行基础、以 WTO 电子商务

谈判为发展重点的数字贸易规则发展进程中,中国还应继续积极参与数字贸易例外规则的制定,并根据自身发展情况在数字贸易国际治理挑战中明确立场、攻防得当。

表 4 中国已签署自贸协定中的数字贸易例外规则

协定名称	签署时间	数字贸易例外规则
中国—新西兰自贸协定升级议定书	2021 年 1 月 26 日	例外专章(第 17 章):一般例外援引必要修正后的 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条;安全例外采用修正后的 WTO 安全例外表述,如增加采取与终止不符措施时向自贸区联合委员会的通知义务
RCEP	2020 年 11 月 15 日	1) 例外专章(第 17 章):一般例外援引 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条;安全例外援引必要修正后的 WTO 安全例外 2) 电子商务专章(第 12 章):跨境数据传输与计算设施位置条款,设置公共政策例外与基本安全利益例外
中国—柬埔寨自贸协定	2020 年 10 月 12 日	例外专章(第 15 章):一般例外援引 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条;安全例外援引 GATT 第 21 条、GATS 第 14 条之二
中国—毛里求斯自贸协定	2019 年 10 月 17 日	例外专章(第 16 章):一般例外援引 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条;安全例外规定了基本安全利益例外
中国—新加坡自贸协定升级议定书	2018 年 11 月 12 日	例外专章(第 13 章):一般例外援引 GATT 第 20 条(货物贸易)、GATS 第 14 条(服务贸易);安全例外采用修正后的 WTO 安全例外表述,如增加关键公共基础设施例外。但该升级议定书未特别明确电子商务与货物及服务贸易的关系
中国—智利自贸协定升级议定书	2017 年 11 月 11 日	1) 例外专章(第 12 章):一般例外援引 GATT 第 20 条;安全例外采用与 WTO 安全例外相同的表述 2) 电子商务专章(议定书第 4 章):国内电子交易框架条款规定了国内法规制例外
中国—澳大利亚自贸协定	2015 年 6 月 17 日	例外专章(中国—澳大利亚自贸协定第 16 章、中国—韩国自贸协定第 21 章):一般例外援引 GATT 第 20 条、GATS 第 14 条;安全例外援引 GATT 第 21 条、GATS 第 14 条之二
中国—韩国自贸协定	2015 年 6 月 1 日	

3.1 中国数字贸易例外规则的发展实践

中国签署的区域贸易协定中,数字贸易例外规则的规范文本日趋精细化:形式上,最初是在例外专章笼统列举并援引 WTO 例外规则,目前则在电子商务专章特定条款下增设了单独的例外规定,并对安全例外规则进行了相对清晰具体的情形列举;内容上,更加游刃有余地把握了“原则+例外”的规范形式,对跨境数据传输与计算设施位置条款作出承诺时增设了公共政策与基本安全利益例外,例外专章中安全例外的列举也根据数字时代新变化做了相应调整,如增加与关键通讯基础设施相关的例外情形。

中国已于 2021 年正式申请加入 CPTPP 与

DEPA,这些高水平国际新规则的广度与深度都超越了 RCEP,^①对中国当前数字贸易例外规则体系提出了新挑战。例如,CPTPP、USMCA 设定了 RCEP 未设定的源代码条款及例外;CPTPP 与 DEPA 对跨境数据传输与计算设施位置条款均未设置 RCEP 中的基本安全利益例外;RCEP 在跨境数据传输与计算设施位置条款的公共政策例外中规定,不符措施是否属于实现合法公共政策目标所必要的措施由缔约方自行判断,只要该措施不以构成任意或不合理的歧视或变相的贸易限制的方式适用,但是,CPT-

^① 周念利、于美月:“中国应如何对接 DEPA——基于 DEPA 与 RCEP 对比的视角”,《理论学刊》,2022 年第 2 期,第 55 页。

PP、USMCA、DEPA 等协定中特定公共政策例外并没有将此判断权交由缔约方自身。

3.2 中国数字贸易例外规则的实践方向

目前,数字贸易国际规则制定的主导权和话语权,主要由数字技术与数字经济发展相对迅速的发达经济体来掌握。发达经济体与数字贸易大国主导的区域贸易协定,明显比诸边及多边贸易协定发展更快、要求更高。包括中国在内的广大发展中经济体在数字贸易议题上的失语或失利,不仅不利于有效把握数字经济发展的新机遇,还可能进一步加剧与发达经济体之间的数字鸿沟。中国作为多边贸易体制的发展获益者与秩序维护者,应当充分把握 WTO 要求重振“电子商务工作计划”的契机,积极参与数字贸易诸边协定的制定,以更广范围内达成的规范性共识化解区域数字贸易规则的碎片化影响。

(1) 立足全球数字经济发展,倡导例外规则的包容性

中国应当团结广大发展中经济体,积极参与 WTO 电子商务谈判,倡导例外规则文本的包容性发展。首先,中国应坚定维护多边主义,不因当前的逆全球化浪潮与单边主义挑战而迟滞 WTO 电子商务谈判节奏。从长期看,WTO 仍然是整合全球区域性贸易规则的重要国际组织,^① WTO 电子商务谈判是不断完善数字贸易例外规则的重要多边平台。选择多边贸易体制,促进谈判以更开放、包容和透明的方式开展,争取更多利益相关方平等参与、平等协商,有助于提升未来数字贸易规则的包容性。其次,中国还应为提高发展中经济体对谈判的参与度做出贡献。中国可以进一步参与 WTO 对发展中经济体成员的发展援助工作,为其参与谈判提供必要的技术支持,共同克服国际规则谈判能力和参与能力贫困的局限性,^②进而以更强大的集体力量、更稳定的共同利益诉求来争取合法合理的权益。最后,规则实体内容本身的包容性也应有所提高。数字贸易例外规则设定所面临的核心选择是:在多大程度上推崇数字贸易自由

化,在多大限度内让渡数字领域的国家规制权。以数据跨境流动为例,尽管不应限制数据自由流动已成为谈判各方认同的基本立场,但各方往往会做出例外安排。为此,必须在例外规则中对个人、消费者与病患等隐私,网络安全,犯罪,言论自由、获取信息、非歧视等人权,虚假信息等公共政策目标与安全目标进行充分探讨。^③中国提出,网络安全、数据安全与隐私保护等复杂问题日益凸显,数字贸易规则谈判设定的目标水平应更加合理,应充分考虑各方基于不同发展阶段、法律制度与历史传统而存在的规制差异,对技术进步及贸易发展等自由化目标、网络主权及数据主权等公共政策目标进行平衡。^④接下来的 WTO 电子商务谈判中,中国应当进一步立足全球数字经济发展,促进一致性、包容性的规范共识形成。

(2) 防止例外规则滥用,增强例外规则适用的严肃性

国际贸易例外规则的适用一直都存在一种两难境遇:如果援引成本过高、难度过大,缔约方在遭受经济重挫时将因无法灵活设定贸易政策而选择违反贸易协定,破坏贸易体制与条约的稳定性;如果援引成本过低、难度过小,缔约方又可能会因滥用例外规则而贬损条约的权威和可靠性;这两种情况无疑都影响了贸易自由化目标的实现。^⑤个别国家一边高举贸易自由化大旗要求他国不断降低关税、开放市场,一边又因意识形态、单边主义、霸权思维等不合理因素随意借例外规则之名行贸易保护之实,援引例外规则的严肃性无法被保证。对此,中国可以与各成员方一同在 WTO 电子商务谈判中对

① Richard Baldwin, "Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade," *World Economy*, Vol. 29, No. 11, 2006, p. 1508.

② 张向晨、徐清军、王金永:“WTO 改革应关注发展中成员的能力缺失问题”,《国际经济评论》,2019 年第 1 期,第 9 页。

③ WTO, Exploratory Work on Electronic Commerce, Non-Paper from Brazil, INF/ECOM/3, 25 March 2019, p.5.

④ WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Communication from China, INF/ECOM/19, 24 April 2019, pp. 1-2.

⑤ 韩逸畴:“国际规则的‘结构性挑战’:以贸易协定中的例外规定为例”,《当代法学》,2021 年第 4 期,第 145 页。

例外规则的具体情形和适用条件进行更清晰严肃的澄清和规范,从而加深各方共同的适用理解;也可以考虑将此类争议诉至争端解决机构,通过争端解决机构对不符措施必要性及正当性的审查来敦促违反承诺的国家或地区保持足够的自我克制。

数字贸易例外规则中最容易被滥用的可能是安全例外,一方面各方对数字贸易语境下和网络空间中的基本安全利益还没有形成广泛共识,另一方面安全例外规则的“其认为”措辞赋予了各方比判定一般例外时更大更明确的自由裁量权。“国家安全”一直是美国政府推行贸易保护措施、根据国内法单方挑起贸易摩擦的主要借口之一。2017年以来,美国以国家安全为由,将中国的众多机构列入出口管制名单与限制交易名单,禁止本国政府、限制他国政府采购中国企业提供的通讯设备和服务,限制中国企业购买或经授权使用本国技术。这些违反WTO协定义务且不属于安全例外的措施,已经严重影响到了中国乃至全球数字贸易基础设施建设,干扰了跨境数字贸易正常往来。对于类似争议,中国除了可以在国际规则制定及争端解决层面付出努力之外,还应在总结商务部《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》实施情况、借鉴域外阻断法立法与实践经验的基础上,构建更高层级的阻断法,进而有效救济与保护数字贸易主体的合法权益。

(3)开展国内压力测试,提高中国援引例外规则的相符性

对于数字贸易相关原则与例外而言,中国新近生效的RCEP已经比过去缔结的区域贸易协定有了长足的进步,但对比CPTPP、USMCA等更高水平贸易协定仍存差距。鉴于美国在国际规则制定中的强势主导地位,中国应在国内层面有效开展数字贸易规则压力测试。这一点对于志在参与数字领域国际规则与国际标准构建、已经正式申请加入CPTPP与DEPA的中国来说,尤为重要。美国贸易代表办公室(USTR)认为数字贸易和电子商务障碍主要包括数据本地化等跨境数据流动障碍、限制数字产品贸易

的歧视性做法、互联网服务限制以及其他限制性要求,该办公室还连续多年对其认为的各国数字贸易壁垒进行了梳理汇总。各国为了自身公共政策、秩序或道德等目标而设定的相关规制要求,被美国贸易代表办公室认定对数字贸易施加了不必要限制,增加了不必要成本。对此,希望中国等处于数字贸易发展初期的发展中经济体可以保持警醒,充分认识到数字贸易国际规则在美国主导下的高度自由化倾向,把握数字贸易与数据流动自由度不断提高的发展大势,积极开展相关领域的压力测试,从而找到自身公共政策目标与自由开放之间的最佳平衡点。

值得欣喜的是,2021年9月,中国在顶层设计上正式提出将加强服务领域规则建设,习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞表示,将支持一些地方开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试,打造数字贸易示范区。国务院《“十四五”数字经济发展规划》提出加快贸易数字化发展,以数字化驱动贸易主体转型和贸易方式变革,营造贸易数字化良好环境。RCEP的正式实施,也有助于推动形成“以货物贸易数字化为核心、以服务贸易数字化为延伸,以数字基础设施互通和安全为保障”的数字贸易发展产业链和生态圈,助力中国特色数字贸易示范区建设。地方层面,2022年颁布的一些地方性立法中,已经明确提出“推进国际数据港建设,构建国际互联网数据专用通道”“探索制定低风险跨境流动数据目录,促进数据跨境安全有序流动”“探索推进数字贸易规则制度建设,培育国际化的数字贸易品牌”等,^①这些都有助于中国进行国内压力测试,对接高标准国际数字规则和参与数字贸易规则治理。

四、结 语

近期,WTO第十二届部长级会议达成《关

^① 参见《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区条例》,2022年2月18日。笔者曾有幸参与该部法律的前期论证工作。

于《电子商务工作计划》的部长决定》,提出重振“电子商务工作计划”下的工作,完善数字贸易规则必将受到更多关注。数字贸易例外规则的规范差异与演进趋势,反映出各国对数字贸易自由化与国家规制主权的动态平衡。不同区域贸易协定下的数字贸易例外规则呈现不同特点,在USMCA、USJDTA等协定中更趋严格,在RCEP、CETA等协定中更显慎重,在DEPA、SADEA等协定中更为中和。区域性协定中例外规则的规范性差异,有待各方通过更符合广泛共识的诸边与多边规则来进行协调,进而降低规则碎片化带来的不利影响。面对多边及诸边规则滞后、区域规则纷繁多样的现状,我们必须认可区域及双边条约对数字贸易等新议题的更强突破力,也必须承认:在诸边甚至多边层面,形成更被各方广泛认可、更利于各方普遍受益的数字贸易国际规则,才是数字贸易国际治理的更高

目标。数字贸易“原则+例外”的规则体系,彰显了数字贸易国际治理的立法智慧。为了数字贸易例外规则及其适用能够真正促成贸易自由与规制主权的价值平衡,世界各经济体还需要在WTO电子商务谈判中对例外规则的具体内容与条件设定展开更深入讨论,并用科学灵活的方式将更广泛的规范性共识确定下来。特别是发达经济体,也应在数字贸易实践中克制权力导向的冲动,遵循善意履行条约的国际法原则,发挥国际合作、秩序与法治对数字贸易发展的驱动作用。对中国而言,当前需要把握住数字贸易例外规则为国内数字贸易发展提供的规制空间,积极开展压力测试和数字领域制度型开放创新,有效推进数字贸易示范区的建设,为数字贸易和数字经济发展提供良好的外部环境。

编辑 邓文科

Types and Evolution of Digital Trade Exception Rules and China's Responses

LI Zhenfei¹ PENG Delei²

(1. *The First Intermediate People's Court of Shanghai Municipality, Shanghai 200336, China*; 2. *East China University of Science and Technology, Shanghai 200240, China*)

Abstract: The digital trade exception rules are the concentrated embodiment of seeking the dynamic balance between trade liberalization and states' regulatory rights in the field of digital trade. The digital trade exception rules can be observed in various bilateral and regional trade agreements and digital economy agreements. They are generally aligned with the setting mode, normative expression and functional positioning of the WTO exception rules, although they have differences in typology and normative guidance. And there is a tendency of expansion in the application and recognition of digital trade exception rules in regional agreements. As far as China is concerned, there is a big gap between the digital trade exception rules in the existing treaties and similar arrangements in the new international rules, such as the CPTPP and the DEPA. The research on the types and evolution of digital trade exception rules will help China properly deal with the regional and multinational negotiations of digital trade rules, actively participate in the work under the Work Programme on Electronic Commerce reinvigorated by the WTO, and fully grasp the regulatory space provided by the exception rules to promote the institutional opening and innovation in digital trade, so as to promote the development of digital economy.

Key words: digital trade; exception rules; trade liberalization; regulatory rights